

3002043-89.2013.8.26.0457

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

3002043-89.2013.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

3002043-89.2013.8.26.0457

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberta Cristina Vignali Maia

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de Roberta Cristina Vignali Maia, já qualificada nos autos, como incurso no topo do artigo 180 do Código Penal afirmando que em 04 de dezembro de 2013, por volta das 21h45min, no interior do posto de serviços "Marauto", situado na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, nº 531, Centro, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, recebeu e ocultou em sua residência um aparelho de telefone celular da marca "Iphone", pertencente à Paulo José Cione Cristino da Silva.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "na data dos fatos, a vítima foi ao Posto Marauto e, ao pagar sua compra, esqueceu seu celular sobre o balcão. O denunciado Ricardo, aproveitando-se deste fato, subtraiu-o para si e foi embora para a cidade de Pirassununga em companhia da denunciada Roberta. No caminho, entregou o celular para ela, que, sabendo de sua origem espúria, recebeu-o e o ocultou em sua residência em Pirassununga. Ocorre que, no dia seguinte, por meio do aplicativo de seu telefone, o ofendido conseguiu saber onde ele estava, ou seja, na Rua São Vicente de Paula, nº 516, na cidade de Pirassununga. A Polícia Militar foi acionada e para lá se dirigiu, vindo a encontrar o objeto na posse da denunciada Roberta."

A denúncia, que inicialmente acusava também Ricardo, foi recebida (fls. 52 - 24/06/2014). Posteriormente o processo foi suspenso por dois anos nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95 (fls. 65 - audiência de 30/09/2014). Cumprido o acordo, a

punibilidade contra Ricardo foi declarada extinta por sentença de fls. 141/142, ocasião em que o benefício da lei especial conferido a Roberta foi revogado. A sentença foi publicada em cartório em 20/05/2017.

A sentença foi impugnada por recurso em sentido estrito, sendo mantida pela instância superior (fls. 259/263).

O processo, então, seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação:

Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquire coisa produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé também o faça (cf. Nucci, Código Penal comentado, item 1 da glosa ao art. 180).

No caso em exame, há prova da existência e da autoria da receptação própria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 26/29), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo auto de avaliação (fls. 30) pelo auto de entrega (fls. 05) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A suposta vítima, Paulo José Cione Cristino da Silva, na fase policial disse que "na data de ontem, por volta de 21:45, o declarante esteve no no posto de serviços Marauto, localizado na cidade de Porto Ferreira, onde abasteceu seu veículo. Ao efetuar o pagamento no caixa, o declarante deixou seu aparelho telefônico Iphone, marca Apple, sobre o balcão, vindo a esquece-lo naquele local. Que recorda-se que havia um casal logo atrás do declarante, onde o indivíduo aguardava para também efetuar o pagamento, ao passo que a mulher pegou a chave do banheiro no caixa. Que o declarante deu por falta do telefone celular assim que chegou no hotel onde se hospeda naquela cidade, retornando imediatamente na sequência ao posto a fim de recuperar o bem, mas não o encontrou mais, tampouco os funcionários daquele estabelecimento sabiam informar sobre o paradeiro do aparelho. Que o declarante não chegou a registrar a ocorrência de furto na data de ontem, mas nesta data, a partir de aplicativo desse tipo de aparelho, como o mesmo foi ligado pela pessoa que o subtraiu, o declarante tomou conhecimento de que o mesmo estava nesta cidade de Pirassununga, na Rua São Vicente de Paulo, segundo sinal emitido. Que o declarante veio a esta cidade e passou tal informações a policiais militares, os quais se dirigiram até o local indicado e acabaram encontrando o aparelho respectivo na residência da indiciada Roberta Cristina Vignali Maia, pessoa que prontamente o declarante reconheceu como sendo a mulher que estava no posto na data de ontem, acompanhada de seu namorado, o qual esperava para pagar logo atrás do declarante,

sendo então conduzidos a esta Distrital." Em juízo ressaltou que a atendente do posto de gasolina lhe disse que a mulher teria subtraído o celular após o esbarrão dado pelo companheiro dela; a atendente lhe disse que esta mulher teria feito isso outras vezes. Assim que o sinal do seu telefone voltou (percebeu isso pelo iPad), passou a ligar para ele, mas a pessoa não atendia. Foi até a delegacia de Pirassununga e depois foi até a casa do avô de Roberta encontraram o telefone embaixo do travesseiro dela. Viu Roberta dentro da residência. Era a mesma mulher que estava no posto. Furto foi de noite e a recuperação se deu na manhã do dia seguinte. Não tem nenhuma dúvida acerca do reconhecimento. Quando os PMs pegaram o telefone, lhe entregaram e ele fez o desbloqueio. Tinha dados pessoais no telefone, como fotos, mensagens, contatos.

A testemunha de acusação, o policial militar Luis Frederico da Silva Fortes, na fase policial disse que "encontrava-se regularmente em serviço quando foi procurado pela vítima Paulo na sede da 3ª Cia da PM, noticiando ter tido seu aparelho celular Iphone furtado na data de ontem, por volta de 21h45min, em um posto de serviços na cidade de Porto Ferreira, e que por volta das 00h44min recebeu sinal de localização do GPS indicando o local onde o aparelho se achava. Que o depoente, juntamente com o SD Milton deslocaram-se até o local dos fatos, residência da indiciada, onde após autorização do proprietário Orlando Maia Neto, adentraram na residência para efetuar buscas, localizando o aparelho furtado. Que apresentado o aparelho à vítima, esta o reconheceu de pronto como sendo seu, e também reconheceu a indiciada Roberta como uma pessoa que se encontrava na companhia de um rapaz na loja de conveniência do posto de combustíveis, local em que ocorreu o furto. Que a indiciada declarou que foi seu amigo quem subtraiu o aparelho, pedindo para que ela o guardasse em sua bolsa e posteriormente em sua casa." Em juízo manteve sua versão. Roberta havia escondido o aparelho no interior de uma fronha e confessou ter subtraído em Porto Ferreira.

A testemunha de acusação, o policial militar Milton César de Oliveira, na fase policial disse que "encontrava-se regularmente de serviço juntamente com o CB PM Fortes, quando a vítima chegou à 3ª Cia da PM informando que teve seu celular Iphone furtado na data de ontem, em um posto na cidade de Porto Ferreira, porém conseguiu a localização deste através de um sistema de GPS do fabricante, o qual apontava que o aparelho se encontrava no local dos fatos, residência da indiciada. Que o depoente e seu colega de farde se dirigiram até o local indicado pelo GPS e, em busca realizada na residência, foi localizado o aparelho celular, o qual a vítima de pronto reconheceu como sendo seu, bem como reconheceu a indiciada, a qual estava acompanhada de um rapaz no mesmo posto de conveniência em que teve seu celular furtado. A indiciada foi conduzida ao P.S. Local, e posterior apresentada nesta Unidade Policial." Não foi ouvido em juízo.

Roberta Cristina Vignali Maia, em declarações perante a autoridade policial disse que "na data de ontem, entre as 21 e 22h, a interroganda se dirigiu à cidade de Porto Ferreira em companhia de seu amigo Ricardo Silva, residente neste cidade mas em endereço que ignora, tendo parado em um posto de serviços, onde Ricardo foi abastecer seu veículo VW/Golf, cor prata. No momento em que Ricardo foi pagar pelo abastecimento no caixa, a interroganda o acompanhou e pegou a chave do banheiro, a fim de fazer uso, enquanto Ricardo permaneceu aguardando para pagar. Que a interroganda voltou do banheiro e entrou no carro, esperando Ricardo que estava na loja de conveniência. Quando Ricardo entrou no veículo, entregou à interroganda um telefone celular Iphone, cor branca, pedindo que o segurasse. Que Ricardo disse que o havia pego por engano. Que a interroganda não sabe informar se Ricardo possui aparelho celular Iphone e também não viu se este estava na posse de algum outro celular. Que retornaram para Pirassununga, onde Ricardo deixou a interroganda em sua casa, pedindo para que ficasse com o aparelho, o que aceitou. Que na manhã de hoje, policiais militares estiveram na casa da interroganda, informando que sabiam que o telefone se encontrava ali, pedindo para promover uma busca na casa a fim de esclarecer os fatos, tendo então o localizado no quarto da residência da frente, onde a interroganda o deixou, conduzindo-a então a esta Distrital." Não foi ouvida em juízo, sendo revel.

Apesar da negativa da acusada na fase policial e da tese da defesa técnica de ausência de dolo, a versão defensiva não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos da vítima e da testemunha foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Aliás, o relato da vítima apontou Roberta como autora da subtração em coautoria com seu companheiro, o que ensejaria a desclassificação para o delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela destreza. Todavia, diante da manifestação do Ministério Público e em obediência ao art. 3º-A do Código de Processo penal, mantenho a imputação original.

Quanto à tese defensiva, diante dos depoimentos seguros e coesos da vítima e das testemunhas de acusação, considera-se inequívoca a prática da receptação. Não merece credibilidade a versão da ré – desprovida de qualquer comprovação – de que tinha acabado de comprar referido bem de terceiro. Tratando-se de mercadorias ilícitas, caberia a ela demonstrar sua boa-fé e a origem dos bens, o que não ocorreu.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, o que, na vertente hipótese, não ocorreu. Confira-se:

É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato. TJ/SP, Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 10.11.2011)

Neste sentido, diante das provas convincentes, obtidas ao longo de toda a persecução, e que não foram rechaçadas por nenhum subsídio concreto, é inarredável a condenação da ré pelo crime previsto no topo do artigo 180 do Código Penal, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é

ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.
AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.
AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.
Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.
(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...) Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que o valor do bem é considerável (fls. 30 – mais de R\$3.500,00 na correção conforme a Tabela Prática do TJSP), razão pela qual elevo a pena em um terço do seu intervalo.

Na análise das circunstâncias do delito, observo que o seu objeto foi um telefone celular. Como se sabe, hoje esse tipo de aparelho tem um papel central na vida humana, consistindo não só em meio de comunicação telefônica, mas como veículo de acesso a redes sociais, capturador e armazenador de fotos e vídeos pessoais, agenda pessoal, entre tantos outros aspectos que afetam a intimidade. Portanto, aquele que ataca contra esse tipo de objeto expõe a risco a intimidade alheia, ferindo os bens jurídicos tutelados nos incisos X e XII da Constituição. Ora, uma das funções do direito penal é justamente a tutela de bens jurídicos que aumentam a liberdade e a segurança das pessoas; e uma das facetas importantes dos direitos fundamentais é a criminalização de sua violação. Assim, a subtração do telefone pessoal extrapola demasiadamente aquilo que está insito ao tipo penal constituindo circunstância especialmente grave, conforme os valores protegidos pelo nosso direito, que enseja um aumento de um terço do intervalo de pena nesta fase.

Fixo a pena-base em três anos de reclusão e 243 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa (inciso II do art. 65 do Código Penal), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em reclusão de dois anos e seis meses e 194 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça, de pessoa imputada primária, menor de 21 anos, fixo como inicial o regime aberto.

Substituo a pena por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR Roberta Cristina Vignali Maia à pena de reclusão, pelo prazo de dois anos e seis meses, em regime inicial aberto, bem como a 194 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 180 do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Condeno a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 13 de julho de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA